

1503496-89.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WAGNER DE PAULA CREPALDI

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

WAGNER DE PAULA CREPALDI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, 'j', do Código Penal, porque, no dia 11 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1503496-89.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503496-89.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WAGNER DE PAULA CREPALDI

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

WAGNER DE PAULA CREPALDI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, 'j', do Código Penal, porque, no dia 11 de fevereiro de 2022, por volta das 12 horas, em ocasião de calamidade pública, na Rua da Mooca, nº 100, Brás, nesta cidade e comarca da Capital/SP, trazia consigo, para fins de traficância, 49 (quarenta e nove) invólucros contendo porções de cocaína em "pedra", vulgarmente conhecida como crack, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Na ocasião, possuía consigo a quantia de R\$ 52,00 (cinquenta e dois reais).

A denúncia (fls. 76/78) foi recebida (fls. 86/88), o acusado foi citado e notificado (fls. 103/104) e apresentou Resposta à Acusação (fl. 113).

Ratificado o recebimento da inicial acusatória (fl. 116).

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas comuns e o réu foi interrogado (fls. 116/119).

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu pela prática do crime imputado na inicial acusatória, reconhecendo-se o privilégio previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06. Ainda, "em face das circunstâncias favoráveis do réu", manifestou-se pela concessão do regime aberto e pela substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (fls. 116/118).

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu i) a desclassificação para a infração tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/06, vez que o acusado é usuário de drogas; ii) a fixação da pena-base no mínimo legal; iii) o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, 'j', do Código Penal; iv) a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º da Lei 343/06 em sua fração máxima; v) a fixação do regime aberto; vi) a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos; vii) a concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 118/119).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando as provas dos autos, não obstante as alegações da Defesa, há elementos suficientes para a condenação do acusado.

A materialidade dos delitos restou comprovada pelo(s) Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01/02), Boletim de Ocorrência (fls. 07/08), Termos de Depoimentos (fls. 03 e 04), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 09), Laudo de Constatação (fls. 23/25), Comprovante de Depósito Judicial (fl. 69), Relatório Final (fls. 70/71) e, sobretudo, pelo Laudo Químico-toxicológico Definitivo (fls. 89/91).

A autoria dos crimes ficou demonstrada pela prova oral colhida em juízo, cotejada com os demais elementos de prova contidos nos autos.

Hugo Henrique Bratti, policial militar, contou que estava juntamente de seu companheiro de farda, Bruno, em suas motocicletas efetuando patrulhamento pela Rua da Mooca; avistaram o acusado, o qual, agindo de forma suspeita, tomou rumo diferente daquele que vinha caminhando. Em face da conduta estranha do réu, decidiram pela abordagem. O acusado tinha consigo 07 (sete) pedras de crack e quantia em dinheiro em sua pochete – R\$ 87, 00 (oitenta e sete reais). Indagado, WAGNER disse que o entorpecente era para seu uso pessoal. Narrou que, próximo de ontem estavam, cerca de um metro, localizaram uma sacola que continha mais 42 (quarenta e duas) pedras de crack, além de R\$ 14,00 (quatorze reais). Esclareceu que, quando visualizaram o réu antes da abordagem, ele já estava próximo à sacola com as drogas. Depois de algum tempo, o acusado confessou informalmente a traficância. Alinhavou que a droga encontrada na pochete do acusado estava embalada com o mesmo plástico que envolvia a droga contida na sacola localizada junto ao réu. No momento da diligência, o acusado não aparentava ter feito uso recente de drogas; não conhecia o réu de outras ocorrências.

O policial militar Bruno da Silva Teodoro prestou depoimento harmônico e congruente, no mesmo sentido de Hugo. Acrescentou que não chegou a ver o acusado "mexer" na sacola localizada próximo a ele. Não era possível asseverar que o réu encontrava-se em situação de rua; não se recorda se WAGNER estava calçado.

Em solo policial, o acusado negou a prática delitiva (fl. 05).

Em juízo, WAGNER, 46 (quarenta e seis) anos, negou a prática delitiva. Afirmou que é mero usuário de entorpecentes. Contou que foi preso descalço, pois é morador de rua. Passou por 15 (quinze) internações, inclusive na "Missão Belém". Asseverou que a droga era realmente sua, mas destinava-se ao seu consumo pessoal. Repisou que é usuário de crack, droga que consome de forma excessiva, de 20 (vinte) a 35 (trinta e cinco) pedras por dia. Alinhavou que é conhecido no local dos fatos, embaixo de um pontilhão, lugar onde vive. Usa o auxílio que recebe do governo para comprar os entorpecentes. No dia da ocorrência, estava sujo e com diarreia. Responde, atualmente, pelo crime de furto perante outro juízo. Contou que possui 03 (três) filhos e é divorciado. Vive em situação de rua desde o ano de 2009.

Estas são as provas trazidas pelas partes e, diante delas, outra solução não há que condenar o acusado pelo crime a ele imputado na denúncia.

Por primeiro, a versão do acusado ficou isolada do conjunto probatório. Veja-se que, aliado aos depoimentos dos policiais, a quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento e o local em que o réu estava já são suficientes para caracterizar o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, restando provada a origem espúria da quantia apreendida. A este propósito, é expressiva a jurisprudência, merecendo destaque o seguinte julgado: RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do entorpecente. 3. Recurso especial provido, para cassar o acórdão recorrido e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória. (REsp nº 1361484/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 10.06.2014, DJe 13.06.2014).

É de asseverar, ainda, que o simples fato de testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Saliente-se que pequenas divergências em seus relatos, normais em virtude de participarem de várias diligências semelhantes, não retiram o valor probatório dos depoimentos, porquanto seus aspectos nucleares afiguram-se congruentes e concatenados.

Por conseguinte, é idônea a prova oral produzida pela acusação.

De outro lado, o pedido de desclassificação formulado pela defesa técnica não comporta acolhida.

A condição de dependente químico não tem o condão de excluir automaticamente o enquadramento típico do crime de tráfico de drogas, notadamente porque, em grande parte dos casos, os usuários de entorpecentes, infelizmente, praticam a mercancia ilícita para conseguirem sustentar o próprio vício. Nesse sentido:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJTJ 101/498).

Em outras palavras, o pedido não veio amparado por qualquer documento ou testemunho contundente que fizesse possível a desclassificação pretendida, não tendo a defesa suplantado o ônus que lhe recaía (CPP, art. 156).

Diante de todo o conjunto probatório formado nos autos, ficou exaustivamente atestado que a droga encontrada com o réu, bem como dentro da sacola que estava junto a ele, realmente destinar-se-ia ao consumo de terceiros.

Portanto, caracterizada a infração penal, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime) e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, tem-se que a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo cominado à espécie, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a sanção permanece inalterada.

Neste ponto, nada obstante o preclaro entendimento da i. representante do Ministério Público, a agravante da calamidade pública deve ser afastada, porquanto não existem elementos suficientes que indiquem que o acusado aproveitou-se da situação da emergência sanitária da pandemia da COVID-19 para praticar o delito imputado. Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: "[...] A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito. [...]" (STJ - HC 654255/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 25/05/2021, p. 07/06/2021).

Na terceira etapa, deve ser levada em consideração a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, causa esta que, uma vez

verificados seus requisitos, deve ser aplicada, ainda que de ofício. Observando-se o critério da proporcionalidade e razoabilidade no caso em questão, tem-se que a pena deve ser reduzida em 2/3 (dois terços), nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, visto que o réu é tecnicamente primário e tem bons antecedentes. Resta, portanto, sua pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

A este respeito, deve ser acolhido o seguinte preceito doutrinário: “Dispõe o parágrafo, em sua parte final, sobre condições negativas de que o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Toda prova negativa é difícil, de modo que militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, no caso, é do Ministério Público no sentido de demonstrar a reincidência, os maus antecedentes e a participação em atividades criminosas ou organização criminosa. Não importa que a prova seja difícil para o Ministério Público. Mais difícil seria para o réu que, por sua vez, tem o direito de não ser condenado a não ser que haja prova, ou receber, sem prova, uma pena maior quando a lei permite uma pena mais branda” (GRECCO FILHO, Vicente e RASSI, João Daniel. Lei de Drogas Anotada. São Paulo: Saraiva, 2ª Ed., 2008, p. 106-107).

Com fulcro em tal lição doutrinária e na análise das provas produzidas em juízo, de rigor considerar a causa de diminuição da pena, eis que não restaram comprovados quaisquer dos óbices aduzidos no texto de lei sob comento.

Por conseguinte, excepcionalmente, considerando as particularidades do caso vertente, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, em consonância com o art. 44, § 2º, do Código Penal, sendo duas prestações de serviço à comunidade em locais a serem indicados na fase de Execução.

Em caso de descumprimento da pena alternativa e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto.

Importante ressaltar que o tráfico privilegiado não é definido como crime hediondo, conforme art. 112, § 5º, da Lei de Execução Penal e, portanto, os efeitos decorrentes da hediondez de um delito não são aplicáveis, sendo plenamente possível o regime inicial em modalidade diferente da fechada.

A pena de multa, eis que não substituída, permanece intacta.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado WAGNER DE PAULA CREPALDI como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 33, § 4º, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado, SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, sendo duas prestações de serviços à comunidade em locais a serem definidos pelo juízo da Execução.

Expeça-se alvará de soltura clausulado. Intime-se o réu do teor da sentença no ato da soltura, indagando-o se deseja recorrer do édito condenatório.

Após o trânsito em julgado, determino, desde logo, a destruição das amostras das drogas apreendidas eventualmente guardadas para a contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, devendo a serventia certificar o cumprimento nos autos.

Oficie-se. Adite-se a carta de guia, se necessário, elaborando-se o cálculo da pena de multa aplicada.

Decreto a perda dos valores apreendidos em favor da União, conforme o artigo 63, §1º, da Lei 11.343/06.

O réu fica dispensado do recolhimento das custas processuais, vez que assistido pela Defensoria Pública Estadual e, no cenário dos autos, presume-se a hipossuficiência de recursos.

Após o trânsito em julgado, expeça-se Guia de Execução Definitiva e lance-se o nomes do sentenciado no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA